

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합 · 이송>

[기출][2018-3]영업정지처분 취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송의 병합 적법 여부

《[문제3] 사업자 甲은 위법을 이유로 행정청으로부터 2개월 영업정지처분을 받았다. 이에 대한 甲의 처분취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송이 병합될 수 있는지 설명하시오. (25점)》

<문제3> 영업정지처분 취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송의 병합 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 사업자 甲은 위법한 영업정지처분에 대하여 처분취소소송을 제기함과 동시에 해당 처분으로 발생한 영업 손해에 대한 국가배상청구를 함께 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <항고소송과 국가배상청구소송이 관련 청구로서 행정소송 절차상 병합될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송과 국가배상청구소송의 병합 가능성과 그 요건을 검토한다.

II. 관련 청구소송 병합의 일반 법리

1. 관련청구소송 병합의 의의 및 범위

(1) 의의 및 취지

- "행정소송법 제10조 제1항"은 주된 처분등의 취소소송에 관련청구소송을 병합하여 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 하나의 처분에서 파생되는 다양한 법률적 분쟁을 동일한 법원 내에서 한꺼번에 해결함으로써 소송경제를 도모하고 판결의 모순 · 저축을 방지하기 위함이다.

(2) 관련청구의 범위

- "동법 제10조 제1항 제1호"는 당해 처분과 관련되는 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등의 청구소송을 관련청구소송의 하나로 규정하고 있다. 처분의 위법을 원인으로 하는 국가배상(손해배상)청구는 전형적인 관련청구에 해당한다.

2. 소의 병합 요건 및 관할 법원

(1) 주된 청구의 적법성 및 시기적 한계

- 소의 병합이 적법하기 위해서는 주된 송인 취소소송이 적법하게 제기되어 수소법원에 계속 중이어야 한다. 또한 추가적 병합의 경우 사실심 변론종결 전까지 이루어져야 하며, 주된 청구가 부적법하여 각하되는 경우에는 병합된 관련청구 역시 부적법 각하를 면할 수 없다.

(2) 수소법원의 관할권 확보

- "대법원"은 국가배상청구소송의 법적 성질을 공법상 당사자소송이 아닌 민사소송으로 파악한다. 그러나 "행정소송법 제10조"의 병합 규정은 특별한 관할 창설 규정이므로, 수소법원인 행정법원은 원래 민사소송인 국가배상청구소송에 대해서도 관련청구로서 적법하게 관할권을 행사하여 이를 심리 · 판단할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 국가배상청구의 관련청구 소속 여부

(1) 처분과의 관련성

- 사안에서 甲이 청구하고자 하는 국가배상청구는 행정청이 내린 2개월 영업정지처분의 위법성을 원인으로 하여 발생한 영업 손해의 전보를 구하는 소송이다. 이는 "행정소송법 제10조 제1항 제1호"에서 규정하는 당해 처분과 관련되는 손해배상청구소송에 정확히 부합한다.

(2) 민사소송과의 관계

- "판례"의 태도에 의하더라도 국가배상청구는 실체법상 민사소송에 불과하나, 영업정지처분 취소소송이라는 주된 항고소송에 흡수되어 병합될 수 있는 적격(관련청구소송의 지위)을 명백히 취득한다.

2. 병합의 구체적 적법성 검토

(1) 주된 송과의 연계성

- 甲이 영업정지처분의 위법을 주장하여 제기하는 취소소송이 제소기간 등 소송요건을 모두 충족하여 적법하게 계속 중인 상태라면, 사실심 변론종결 전에 영업 손해에 대한 국가배상청구소송을 병합하여 제기하는 소송 형태는 적법하다.

(2) 수소법원의 심리 가능성

- 수소법원인 행정법원은 주된 영업정지처분의 위법성 여부를 직접 심사하면서, 그와 연계된 국가배상법상 공무원의 고의 · 과실 및 인과관계 유무를 종합적으로 심리하여 본안판결을 내릴 수 있는 사법적 권한을 가진다.

IV. 결론

- 사안에서 사업자 甲이 행정청의 2개월 영업정지처분에 대하여 제기한 취소소송과 그로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송은 병합하여 제기될 수 있다. 국가배상청구는 "행정소송법 제10조 제1항 제1호"가 규정하는 당해 처분과 관련되는 손해배상청구로서 전형적인 관련청구소송에 해당하기 때문이다. "판례"가 국가배상소송을 민사소송으로 취급하더라도 행정소송법상 특별 관할 규정에 의해 행정법원이 관련청구로서 관할권을 가지므로, 주된 취소소송이 적법하게 계속 중이고 사실심 변론종결 전까지 병합이 이루어진다면 법원은 두 소송의 병합을 적법한 것으로 판단하여 실체적 심리를 진행하여야 한다.